
NOÇÕES PRELIMINARES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1. FASES DO DIREITO ADMINISTRATIVO
 - 1.1. Ausência do Direito Administrativo (sécs. XV a XVIII)
 - 1.2. Estado Liberal de Direito (fim do séc. XVIII e séc. XIX)
 - 1.3. Estado Social de Direito (início do séc. XX)
 - 1.4. Estado Democrático de Direito
2. CONCEITO e SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
 - 2.1. Conceito
 - 2.2. Sistemas Administrativos
3. INTERPRETAÇÃO e INTEGRAÇÃO do DIREITO ADMINISTRATIVO
 - 3.1. Interpretação do Direito Administrativo
 - 3.2. Integração do Direito Administrativo
4. FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO
5. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO
 - 5.1. Força Normativa dos Princípios
 - 5.2. Princípios em Espécie
6. QUESTÕES

1. FASES DO DIREITO ADMINISTRATIVO

A evolução do Direito Administrativo confunde-se com a própria evolução dos países, partindo de um momento de total ausência de responsabilidade do Estado em relação aos cidadãos e chegando ao momento atual, em que a razão de ser da Administração pública é o atendimento às necessidades da sociedade e a regra é a responsabilidade civil objetiva do Estado.

1.1. Ausência do Direito Administrativo (sécs. XV a fim do século XVIII)

Num primeiro momento, temos uma total ausência do Direito Administrativo no âmbito da Administração pública: é a fase dos Estados Absolutistas.

a) Estados Absolutistas: a era dos Estados absolutos (ou absolutistas) ocorreu no período compreendido entre os sécs. XV a XVIII (anos 1400 a fim dos anos 1700).

Nesse período o Estado não era responsabilizado por seus atos, pois o Estado era personificado na pessoa do rei ("O Estado sou Eu"), que se entendia ser rei em virtude da vontade Divina (o rei era mensageiro de Deus na Terra).

É uma época em que a Igreja (clero) e o Estado (nobreza) estão muito ligados: a Igreja efetivamente influenciava nas decisões dos Estados (países);

b) O Rei não erra ("The king can do no wrong"): é dessa época que temos a famosa frase "O Rei não erra", pois a vontade do Rei era a vontade do próprio Estado (e de certa forma também a vontade de Deus).

Sendo assim, como o rei pratica a vontade divina, ele não erra; e se o rei não erra, o Estado também não erra; logo, o Estado nunca comete danos aos seus súditos (na época nem se falava em cidadãos) e, por isso, não pode ser responsabilizado por seus atos, pois se entendia que ele sempre agia corretamente, em conformidade com o Direito.

c) Poderes concentrados: nesse período era o rei quem criava (legislativo) e impunha (executivo) o Direito aos seus súditos (cidadãos), tendo também total controle sobre o judiciário, pois era o próprio rei quem nomeava os juízes e os destituía quando queria. Ou seja, os três Poderes (legislativo, executivo e judiciário) estavam concentrados na mesma pessoa, o rei.

Somente no séc. XVIII que se conhece a separação dos Poderes, teoria que foi compilada pelo político, filósofo e escritor francês Montesquieu (a partir de então a teoria da separação dos Poderes começa a difundir-se mundo afora).

d) Inimigo do povo: na época dos Estados Absolutistas, o Estado é visto como um inimigo do povo, pois não atuava em favor da população e cometia inúmeras arbitrariedades sem que fosse responsabilizado por isso (ao povo cabia abaixar a cabeça e se conformar).

As pessoas eram súditos do rei, e não cidadãos de direito.

e) Inexistência do Direito Administrativo: por todo o acima visto, diz-se que nesse período não havia Direito Administrativo.

1.2. Estado Liberal de Direito (fim do séc. XVIII e séc. XIX)

As diversas arbitrariedades cometidas pelos reis (Estado) começaram a gerar pressões e revoltas populares, as quais buscavam limitar o enorme poder dos reis.

Chega-se então à segunda fase do Direito Administrativo, que é o seu próprio surgimento, o seu nascimento (como visto, no período absolutista sequer havia Direito Administrativo; agora ele existe).

Trata-se do Estado Liberal de Direito, que se institucionalizou no fim do séc. XVIII, com a Revolução Francesa (1789), e que se preocupava em dar liberdade e igualdade (formal) às pessoas, que agora começam a ser reconhecidas como cidadãos.

A Administração pública deixa de ser totalmente arbitrária (absolutista) e passa a encontrar limites em normas legais.

a) Revolução Francesa (1789): a Revolução Francesa teve papel decisivo na limitação dos poderes dos reis (dos Estados) e, como consequência, foi decisiva para o próprio surgimento do Direito Administrativo e sua estrutura tal como conhecemos hoje.

Perceba-se que a Revolução Francesa foi importante para o Mundo todo não apenas do ponto de vista do Direito: com a limitação dos poderes dos reis da época, as pessoas deixam de ser simplesmente súditos do rei e passam a ter uma vida mais digna, na condição cidadãos, de seres humanos titulares de direitos.

O lema dos revolucionários franceses era liberdade, igualdade e fraternidade (*Liberté, égalité, fraternité*): liberdade aos cidadãos para que pudessem trabalhar e ter lucro, sem que

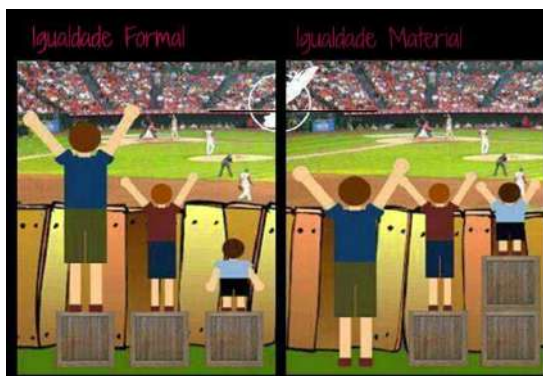
o Estado (rei) tomasse tudo para si; igualdade e abolição das discriminações entre os cidadãos, fossem eles aristocratas, burgueses ou camponeses; e fraternidade com os camponeses, que eram a classe menos abastada da sociedade francesa.

b) Igualdade formal: houve a conquista de um ordenamento jurídico único, no qual todas as pessoas eram iguais perante a lei (igualdade entre todos), afastando-se as discriminações que vigoravam até então.

Mas era uma igualdade formal, o que significa dizer que todos os cidadãos de todas as classes sociais eram tratados de maneira uniforme, sem observância das necessidades e peculiaridades de cada um.

Claro que isso trouxe vantagens para os cidadãos de modo geral, pois antes sequer havia igualdade entre o povo; mas também é inegável que os mais abastados (ricos) acabaram sendo mais privilegiados em relação aos mais necessitados, pois não havia leis protetivas para estes.

A imagem ao lado representa bem a diferença entre igualdade formal e igualdade material.



c) Estado Liberal (Estado "mínimo"): aqui, no Estado Liberal, o que se pregava era a mínima intervenção do Poder Público na sociedade e na economia – economia de livre mercado.

Ou seja, de um Estado absoluto, com total controle sobre a sociedade, passa-se a um Estado mínimo (liberal), que interfere minimamente na sociedade, deixando que ela própria se regule.

d) Estado de Direito: também é nessa fase que se concebe o Estado de Direito, que é aquele submetido a uma Constituição, com separação dos Poderes e reconhecimento de que as pessoas são titulares de direitos, direitos esses que podem ser invocados, inclusive, em face do próprio Estado.

Para o doutrinador Carlos Ari Sunfeld, o Estado de Direito é aquele

[...] criado e regulado por uma Constituição (isto é, por norma jurídica superior às demais), onde o exercício do poder político seja dividido entre órgãos independentes e harmônicos, que controlem uns aos outros, de modo que a lei produzida por um deles tenha de ser necessariamente observada pelos demais e que os cidadãos, sendo titulares de direitos, possam opô-los ao próprio Estado.

e) Separação dos Poderes (funções estatais): muito importante para que o Estado Liberal florescesse foi a separação dos Poderes estatais, de modo que eles não ficaram mais concentrados unicamente na pessoa do rei.

O rei continuou sendo detentor do Poder Executivo (administrar a coisa pública); mas a criação das normas jurídicas passou a ser realizada por um Poder Legislativo independente, composto por parlamentares eleitos pelo povo e não vinculados ao rei; e o Poder Judiciário, apesar de continuar sendo exercido por juízes indicados pelo rei, tornou-se independente porque tais juízes, uma vez indicados pelo rei, não podiam mais ser destituídos por ele (os juízes passaram a ter mandato e o rei não podia mais destituí-los quando bem entendesse).

Quem primeiro percebeu essa "separação" dos três poderes estatais e a sistematizou foi o político, filósofo e escritor francês Montesquieu – ele não "criou" a teoria da separação dos Poderes, como muitos dizem; apenas percebeu que isso aconteceu e sistematizou em seu livro, de 1748, intitulado "O Espírito das Leis".

Portanto, as três principais funções estatais – legislar, administrar e julgar – deixaram de ser exercidas pela mesma pessoa (rei), sendo divididas entre três instituições diversas: Poder Legislativo, exercido por um parlamento eleito pelo povo; Poder Executivo, exercido pelo rei; e Poder Judiciário, exercido por juízes indicados pelo rei, mas com mandato fixo.

Essa teoria difunde-se mundo afora.

f) Supremacia da Constituição: como visto acima, também é do Estado Liberal de Direito a conquista da tese da supremacia da Constituição, que passa a ser a lei suprema (superior) de todos os países.

Ou seja, a Constituição de cada país passa a ocupar o ápice da sua pirâmide normativa e deve ser respeitada por todos, inclusive pelo rei.

g) Direito subjetivo público: é no Estado Liberal de Direito que também se cria a figura do direito subjetivo público, que é o poder do cidadão de exigir seus direitos contra o próprio Estado, coisa que era inconcebível até então.

As pessoas deixam de ser meramente súditos da coroa e são elevadas à condição de cidadãos: a população passa a ser detentora de direitos que devem ser tutelados pelo Estado (o poder público deve atuar em favor da sociedade) e, portanto, podem ser invocados em face do próprio Estado.

h) Direitos de primeira dimensão (geração): é nesta fase que se criam os direitos de primeira dimensão, que decorrem da própria condição de indivíduo da pessoa (ser humano).

Os direitos de primeira geração (dimensão) exigem uma postura absenteísta do Estado (negativa), um não agir. Vale dizer: as pessoas livram-se da plena interferência estatal, passando a ter muito mais liberdade.

Características dos direitos de primeira dimensão:

- Plano do ser: os direitos de primeira geração dizem respeito à própria condição de indivíduo, de ser humano (plano do ser);
- Postura negativa do Estado: esses direitos exigem uma postura absenteísta do Estado, que deve interferir minimamente na sociedade, deixando que todos exercem seus direitos livremente;
- Liberdades clássicas: os direitos de primeira geração são as liberdades clássicas, tais como aquelas descritas no *caput* do art. 5º da Constituição brasileira, quais sejam, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade ("V.L.I.S.P").

i) Problema: o Estado Liberal de Direito não se mostrou eficiente frente aos problemas sociais, o que decorreu – justamente – da postura absenteísta (não fazer) exigida do Estado; os problemas sociais exigem um fazer do Estado, uma postura intervencionista para resolver os problemas da sociedade.

Na verdade, com a eclosão da Revolução Industrial (liberdade econômica), o Estado Liberal agravou a situação da classe trabalhadora, que passou a viver em condições miseráveis porque era explorada pelos patrões (detentores do capital), sem que o Estado fizesse algo para proteger os trabalhadores.

Isso também ocorreu porque, como visto, a igualdade garantida a todos era apenas formal (e não material), sem observar as peculiaridades de cada um, oportunidade em que a classe empresarial, mais poderosa, passou a explorar a classe trabalhadora (trabalho infantil, jornadas extenuantes de trabalho, baixos salários...), sendo que esta não tinha "força" para se opor àquela. E o Estado não intervinha para proteger os mais fracos: era a lei do mais forte!

Portanto, o liberalismo não conseguiu criar uma sociedade humana e justa, pois a extrema liberdade dada à sociedade (sem qualquer interferência estatal) e a garantia da igualdade

apenas formal entre os cidadãos (sem proteção às classes mais necessitadas), mostrou-se perversa para os menos favorecidos.

1.3. Estado Social de Direito (início do séc. XX)

Em virtude dos problemas do Estado Liberal de Direito, surge o Estado Social de Direito, preocupado com os direitos sociais e em garantir a igualdade material entre os cidadãos (não mais a igualdade apenas formal), que é aquela que observa a condição individual de cada um.

Isso se dá no início do séc. XX, com a Revolução Russa (1917), e se consolida depois do término da Segunda Guerra Mundial (em 1945), objetivando minimizar as mazelas da guerra.

a) Revolução Russa (1917): a Revolução Russa foi decorrente da insatisfação dos trabalhadores da Rússia com a exploração a que eram submetidos pelos seus patrões.

Essa insatisfação espalhou-se por todo o oeste europeu (Europa Ocidental) e, para evitar uma revolta ainda maior, a própria burguesia passou a defender a intervenção estatal nos campos econômico e social para reduzir as mazelas dos trabalhadores.

Percebe-se que a burguesia russa somente defendeu a necessidade de intervenção estatal em favor dos trabalhadores para que a revolução destes não lhes trouxesse maiores problemas.

É o surgimento do Estado Social.

b) Igualdade material (ou substancial): a igualdade material é aquela que não se preocupa unicamente com a igualdade das pessoas perante a lei (igualdade formal), mas sim com a igualdade de fato, que reclama um tratamento desigual conforme a necessidade de cada grupo social.

Lembre-se da imagem existente acima, da diferença entre igualdade formal e igualdade material.

Vale citar a célebre frase de Rui Barbosa (1.849 a 1.923), o patrono da advocacia brasileira:

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoeirar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualem. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade... Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real.

c) Estado do bem-estar social ("Welfare State"): o Estado, então, passa a intervir nas relações econômicas e sociais, preocupando-se com o bem-estar da sua população.

É o Estado do bem-estar social, conhecido pela expressão inglesa *Welfare State*.

Ou seja, se no Estado Liberal o Estado era absenteísta (postura negativa, de não intervir na sociedade), no Estado Social ele passa a ter uma postura ativa (positiva, de agir, intervir), para garantir o bem-estar das classes sociais desfavorecidas.

d) Direitos de segunda dimensão (geração): no Estado Social surgem os direitos de segunda dimensão ou geração, que almejam melhorar a vida e o trabalho do povo, exigindo do Estado uma atuação positiva em favor das classes exploradas.

Características dos direitos de segunda dimensão:

- Plano do ter: os direitos de segunda geração são direitos de conteúdo econômico e social. No Estado Liberal reconhecem-se direitos aos súditos, transformando-os em cidadãos (plano

do ser); aqui, no Estado Social, o Estado age para que esses cidadãos tenham acesso a uma vida digna (plano do ter);

- Postura positiva do Estado: os direitos sociais exigem uma postura proativa do Estado, que deve agir para garantir tais direitos à população;

- Direitos sociais: os direitos de segunda geração ou dimensão são os direitos sociais, como o direito ao trabalho, saúde, lazer, educação, moradia...

e) Constituição do México (1917): apesar de a Constituição alemã de 1919 (conhecida como Constituição de Weimar) ser a mais conhecida, a primeira Constituição do Mundo a consagrar direitos sociais foi a do México, em 1917.

f) Brasil, CF de 1934: no Brasil, a primeira Constituição a reconhecer direitos sociais foi a de 1934, na época do governo de Getúlio Vargas (pai dos pobres), Presidente da República que, posteriormente, consagrou os direitos trabalhistas, criando a CLT.

g) Reflexão: perceba-se a diferença entre o Estado Liberal e o Estado Social:

- *Estado Liberal*: colocam-se barreiras ao Estado, que não deve agir (absenteísmo);

- *Estado Social*: criam-se tarefas ao Estado, que deve agir (prestações positivas).

h) Problema: o Estado Social de Direito hipertrofiou o Estado, pois ele é incapaz de atender a todas as necessidades e anseios sociais – as necessidades sociais são infinitas; mas os recursos são finitos.

Além do mais, foi no Estado Social que se consolidaram regimes autoritários e ditatoriais como a Alemanha nazista de Hitler, a Itália fascista de Mussolini, a Espanha franquista de Francisco Franco, a Inglaterra de Churchill e o Brasil de Vargas (pai dos pobres).

Os governantes desses regimes utilizaram o discurso do Estado Social para fazer promessas de vida digna à população e, ao mesmo tempo, perpetuar-se no poder mediante o uso da oratória e da força, ferindo as garantias individuais e impedindo a efetiva participação popular nas decisões políticas – no nosso caso, o Presidente Getúlio Vargas, o “pai dos pobres”, implementou uma ditadura.

1.4. Estado Democrático de Direito

O Estado Democrático de Direito surge como uma tentativa de corrigir as falhas verificadas no Estado Social, que não conseguiu implementar a justiça social na plenitude que se almejava nem garantir a efetiva participação democrática do povo no processo político, pois, como visto, foi justamente nessa época que surgiram diversos governos autoritários mundo afora.

a) Estado Democrático: Estado Democrático é aquele que respeita a origem do poder, que é o próprio povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos (democracia).

Perceba-se que a razão de ser de um Estado é o próprio povo; sem povo, não há nação.

O Estado Democrático surge como uma forma de barrar a propagação de regimes totalitários, nos quais os governantes, de forma autoritária e com o uso da força, vinham perpetuando-se no poder, em benefício próprio, impondo a sua vontade à população.

Democracia é significado de participação efetiva e operante do povo na coisa pública, o que não ocorria durante o período do Estado Social.

Vale citar a célebre definição de democracia dada por Abrahan Lincoln (1809 a 1865), o 16º Presidente dos EUA, ainda muito antes da consolidação dos Estados Democráticos: "*Governo do Povo, Pelo Povo, para o Povo.*"

b) Direitos de terceira dimensão (geração): é no Estado Democrático Social que surgem os direitos de terceira dimensão ou geração, que são os direitos coletivos (difusos).

Características dos direitos de terceira dimensão:

- *Plano do respeito:* os direitos de terceira dimensão são direitos de conteúdo fraternal (relembrando que os de primeira dimensão são do plano do ser e de segunda dimensão são do plano do ter);
- *Postura positiva do Estado:* assim como nos direitos de segunda dimensão, nos de terceira também se exige uma postura proativa (um agir, um fazer) do Estado;
- *Direitos coletivos:* os direitos de terceira dimensão são os direitos transindividuais ou metaindividuais, pertencentes à coletividade, como a autodeterminação dos povos, a moralidade administrativa, o respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a paz...

c) Brasil, CF de 1988: nossa atual Constituição Federal proclama expressamente o Estado Democrático e de Direito logo em seu art. 1º: "*Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos*".

Inclusive, nossa Constituição vai além e organiza a República Federativa do Brasil com fundamentos presentes nas três fases do Direito Administrativo estudadas:

- *Estado Liberal (primeira dimensão de direitos: art. 5º):* adota a supremacia da Constituição, limita o Poder estatal e assegura o respeito aos direitos individuais, o que exige uma postura absenteísta (não fazer) por parte do Estado brasileiro;
- *Estado Social (segunda dimensão de direitos: art. 6º):* garante direitos sociais que exigem uma postura positiva e dirigente (fazer) do Estado;
- *Estado Democrático (terceira dimensão de direitos: art. 4º):* assegura a participação popular nas decisões políticas, repudiando governos autoritários.

2. CONCEITO e SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

2.1. Conceito

Segundo o doutrinador Rafael Carvalho Rezende Oliveira,

O Direito Administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto as regras e os princípios aplicáveis à atividade administrativa preordenada à satisfação dos direitos fundamentais.

Para os doutrinadores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, Direito Administrativo é o

Conjunto de regras e princípios aplicáveis à estruturação e ao funcionamento das pessoas e órgãos integrantes da administração pública, às relações entre esta e seus agentes, ao exercício da função administrativa, especialmente às relações com os administrados, e à gestão dos bens públicos, tendo em conta a finalidade geral de bem atender ao interesse público.

→ Ausência de codificação: diferente do que ocorre com outros ramos do Direito, que possuem codificações próprias (CC, CPC, CP, CPP, CDC, CLT, CF...), o Direito Administrativo não possui um código próprio – o que temos são diversas leis esparsas, que devem ser estudadas.

Para complicar mais um pouco, cada um dos Entes Federados – União, estados, DF e municípios – possui autonomia legislativa para editar suas próprias leis sobre Direito Administrativo.

2.2. Sistemas Administrativos

Há dois sistemas administrativos adotados a nível mundial: francês e inglês.

Esses sistemas dizem respeito ao exercício da jurisdição.

→ Jurisdição: jurisdição é dizer o Direito no caso concreto, com caráter de definitividade, produzindo a coisa julgada.

No sistema inglês, a jurisdição é exercida somente pelo Poder Judiciário; no sistema francês, a jurisdição também é exercida pelo Poder Judiciário, mas parte dela é exercida igualmente pelo Poder Executivo.

a) Sistema inglês (jurisdição una): no sistema inglês, é o Poder Judiciário quem decide todo e qualquer conflito de interesse de maneira definitiva (exercício da jurisdição), inclusive aqueles envolvendo o Poder Executivo (a Administração pública).

Ou seja, somente um Poder, que é o Judiciário, exerce a jurisdição.

- Jurisdição una: significa que, no sistema inglês, a jurisdição é exercida por apenas um dos Poderes estatais, qual seja, o Poder Judiciário. É somente ele quem decide todo e qualquer conflito com caráter de definitividade (coisa julgada).

- Dois exemplos:

- Particular X Poder Executivo: quando o INSS (autarquia do Poder Executivo da União) indefere um benefício previdenciário, o cidadão (segurado) pode propor um processo judicial contra o INSS, no Poder Judiciário, sendo que este decidirá a celeuma com caráter de definitividade – ou seja, quem tem a última palavra (jurisdição) é o Poder Judiciário, não o Poder Executivo.

- Particular X Particular: se, num contrato de compra e venda de um terreno entre duas pessoas físicas, uma delas não cumpre a sua parte, a outra pode propor um processo judicial perante o Poder Judiciário, que decidirá esse conflito de interesses de modo definitivo, produzindo a coisa julgada.

- Brasil: em nosso país é adotado o sistema inglês e sua previsão está no inc. XXXV do art. 5º da CF/1988: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

O que esse inciso quer dizer é que nenhuma lei poderá prever que alguma situação não possa ser levada à análise do Poder Judiciário. Ou seja, nenhuma norma jurídica pode excluir do Poder Judiciário a análise de qualquer lesão ou ameaça a direito.

Ex.: a Lei Nacional n.º 8.213/1991 (benefícios do INSS) jamais poderá prever que a decisão do INSS (Poder Executivo) sobre algum benefício previdenciário seja definitiva, vale dizer, que não possa ser levada à análise do Poder Judiciário.

b) Sistema francês (dualidade de jurisdição, contencioso/jurisdição administrativa): já no sistema francês, temos tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo resolvendo conflitos de interesse com caráter de definitividade (coisa julgada); ou seja, ambos exercem jurisdição.

O que acontece é que, no sistema francês, os conflitos de interesse que envolvam o Poder Executivo não são decididos pelo Poder Judiciário, mas sim pelo próprio Poder Executivo (Administração pública), através de um órgão denominado "Conselho de Estado".

Cabe ao Poder Judiciário decidir todos os demais conflitos, ou seja, aqueles que não envolvem o Poder Executivo.

- Conselho do Estado + Poder Judiciário:

- Conselho do Estado (Poder Executivo): é o Conselho de Estado quem julga com caráter de definitividade as controvérsias envolvendo a Administração pública. Suas decisões fazem coisa julgada administrativa (a exemplo da coisa julgada judicial) e não podem ser levadas ao Poder Judiciário;

- Poder Judiciário: ao Poder Judiciário cabe julgar todos os demais conflitos de interesse, ou seja, aqueles que não envolvem o Poder Executivo, a Administração pública.

- Dualidade de jurisdição, contencioso administrativo ou jurisdição administrativa: como o nome sugere e conforme visto acima, no sistema francês há dois Poderes (Judiciário e Executivo) que exercem a jurisdição e decidem os conflitos de interesse com caráter de definitividade, quais sejam, o Poder Judiciário e o Poder Executivo.

- Separação dos Poderes: o sistema francês leva a separação dos Poderes ao extremo, pois não permite que o Poder Judiciário analise ou decida sobre controvérsias que envolvam o Poder Executivo (a Administração Pública).

- Dois exemplos:

- Particular X Poder Executivo: se o sistema francês fosse adotado no Brasil, a discussão sobre o indeferimento do benefício previdenciário pelo INSS (autarquia do Poder Executivo) não deveria ser levada ao Poder Judiciário, mas sim ao Conselho do Estado;

- Particular X Particular: aqui nada mudaria, pois os conflitos envolvendo particulares devem ser decididos definitivamente pelo Poder Judiciário.

- Crítica: no sistema do contencioso administrativo (francês) acaba não havendo imparcialidade na decisão de conflitos que envolvem o Poder Executivo, pois é ele próprio – através do Conselho do Estado – quem julga os conflitos de interesse nos quais é parte interessada.

3. INTERPRETAÇÃO e INTEGRAÇÃO do DIREITO ADMINISTRATIVO

3.1. Interpretação do Direito Administrativo

A interpretação, como o próprio nome sugere, diz respeito ao estudo do alcance das normas jurídicas, interpretando-se o que elas pretendem, o que elas objetivam.

É o que também se chama de hermenêutica: "*interpretação dos textos, do sentido das palavras*" (dicionário online).

No Direito Administrativo utilizam-se os métodos tradicionais de interpretação do Direito, ou seja, os mesmos métodos que são utilizados em todos os demais ramos do Direito.

Abaixo veremos os quatro principais; mas há vários outros.

a) Interpretação lógico-gramatical: esse é o método de interpretação que busca compreender os significados das palavras contidas no texto legal.

Havendo uma obscuridade no texto legal, a interpretação lógico-gramatical limita-se a buscar o sentido do texto mediante o significado literal das palavras; procura-se descobrir qual deve ou pode ser o sentido de uma frase, dispositivo ou norma.

b) Interpretação histórica-evolutiva: nessa modalidade, o intérprete busca descobrir a vontade atual da lei e não a vontade pretérita do legislador.

Essa técnica de interpretação deixa transparecer que o direito é dinâmico e que a norma não deve ficar estática no tempo: ela deve ser interpretada de maneira mutável, sofrendo as influências das transformações ocorridas na sociedade.

Ex.: o crime de adultério, que era previsto no art. 240 do CP, foi revogado pela Lei Nacional n.º 11.106, no ano de 2005; mas, muito antes de 2005, esse crime já não era punido porque se entendia que punir criminalmente alguém (pena de prisão) por ter cometido adultério era algo desproporcional com a evolução da sociedade.

c) Interpretação sistemática: para este critério, as normas jurídicas não podem ser interpretadas isoladamente, pois integram um sistema dotado de unidade e harmonia.

Segundo a doutrina de Carlos Maximiliano, considerado o pai da hermenêutica jurídica, "*consiste o Processo Sistemático em comparar o dispositivo sujeito a exegese [interpretação] com outros do mesmo repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto*".

Ex.: as leis do JEC são silentes sobre a contagem dos prazos em dias úteis, razão pela qual sempre se entendeu que devem ser contados em dias corridos (incluindo feriados e fins de semana); todavia, em 2015 o novo CPC trouxe, de modo expresso (art. 219, *caput*), que somente os dias úteis devem ser considerados na contagem dos prazos.

Como o art. 92 da Lei do JEC (n.º 9.099/1999) menciona que as disposições do CPC se aplicam de maneira subsidiária, a doutrina e a jurisprudência passaram a entender que os prazos do JEC também devem ser contados em dias úteis.

Código de Processo Civil

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. [...]

Lei Nacional n.º 9.099/1999

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

d) Interpretação teleológica: a interpretação teleológica é aquela que busca revelar a finalidade da norma, o fim a que a norma se dirige.

Aqui o intérprete deve levar em consideração valores como o bem comum, o ideal de justiça, a ética, a liberdade, a igualdade... Nesse sentido, o art. 5º da LINDB.

Ex.: o art. 1.514 do CC diz que o casamento é entre homem e mulher; mas na atualidade se reconhece o direito ao casamento dos casais homoafetivos, conforme definido pelo STF.

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Código Civil

Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.

→ Primazia: quando a utilização dos métodos conduz a resultados diferentes no caso concreto, sobretudo nos casos "difíceis", a primazia é pelos métodos sistemático e teleológico.

3.2. Integração do Direito Administrativo

A integração diz respeito ao suprimento de lacunas existentes nas normas jurídicas, para o que são utilizados a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, conforme determina o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

LINDB

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Tem-se uma lacuna quando a norma jurídica aplicável não regula a situação concreta. Dito de outro modo: quando se está diante de uma situação para a qual a norma jurídica que deve ser aplicada não preveja uma solução, tem-se uma lacuna.

Isso ocorre em todos os ramos do Direito e, claro, também no Direito Administrativo.

a) Espécies de analogia: a analogia, ou seja, o suprimento da lacuna não preenchida pela norma jurídica aplicável ao caso, pode ser buscada em outra norma jurídica (aplicável a outras situações) ou nos princípios jurídicos.

- Analogia legal ou "legis": na analogia legal, supre-se a lacuna através da aplicação de uma norma jurídica que regula um caso semelhante.

Ex.: o casamento homoafetivo não é regulado por lei; dessa forma, decidiu-se que para o casamento homoafetivo devem aplicar-se as regras relativas ao casamento heteroafetivo;

- Analogia jurídica ou "iuris": aqui se buscam nos princípios a norma para suprir a lacuna.

Ex.: caso do lançamento de anões X dignidade da pessoa humana (França, 1995).

b) Peculiaridades: todavia, no Direito Administrativo o uso da analogia possui as seguintes peculiaridades que devem ser observadas:

- Normas de Direito público: para suprir lacunas no Direito Administrativo, a analogia somente pode ser buscada em normas de Direito público (nunca em normas de Direito privado).

Ex.: para regular a prescrição administrativa nos casos em que a lei é omissa, o STJ afastou a analogia com o Direito Civil (arts. 205-206, CC), fixando a tese de que, para as omissões, o prazo prescricional deve ser de 5 anos, em analogia ao art. 1º do Decreto-lei n.º 20.910/1932.

- Normas do próprio Ente: a analogia também deve ser buscada em normas editadas pelo mesmo Ente Federado (U+E+DF+M), pois cada um dos Entes possui autonomia no âmbito do Direito Administrativo.

Ex.: STJ não admitiu aplicar o instituto da recondução, previsto para os servidores públicos efetivos federais (art. 29, Lei Federal n.º 8.112/1990), em favor de servidor públicos efetivos estaduais quando a lei do referido Estado for omissa.

- Vedado "in malan partem": por fim, no Direito Administrativo a analogia não pode ser utilizada de modo que prejudique o cidadão, ou seja, *in malan partem*.

Portanto, a analogia, seja legal ou jurídica, não pode ser utilizada para prejudicar o administrado.

Decreto-lei n.º 20.910/1932.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Lei Federal n.º 8.112/1990

Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;

II - reintegração do anterior ocupante.

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30.

4. FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO

Fonte é o ponto de partida: os meios e as formas de revelação do Direito.

Fonte é o lugar de onde o Direito vem, de onde ele nasce.

Em qualquer ramo do Direito estudam-se as suas fontes (não apenas no Direito Administrativo).

a) Lei (normas jurídicas): a lei como fonte do Direito Administrativo deve ser considerada em seu sentido amplo para abarcar todas as espécies de normas jurídicas, o que engloba tratados internacionais, a Constituição, leis infraconstitucionais (ordinária, complementar e delegada) e até mesmo normas infralegais (decretos, regulamentos...).

Ou seja, toda e qualquer espécie de norma jurídica é considerada fonte do Direito Administrativo.

b) Doutrina: doutrina são as opiniões dos estudiosos sobre as normas e os institutos do Direito.

A doutrina não tem a mesma força vinculativa que as leis (normas jurídicas) porque, como dito, são apenas opiniões emitidas sobre determinados temas.

Mesmo assim, a doutrina com certeza influencia o legislador, o administrador público e o julgador (Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário), sendo, por isso, também considerada como fonte do Direito Administrativo (Poder Executivo).

c) Jurisprudência: jurisprudência são decisões reiteradas dos Tribunais (Poder Judiciário) sobre determinado tema, que acaba influenciando a atuação da Administração Pública (Poder Executivo).

Ou seja, a partir do momento em que os Tribunais começam a decidir um tema de uma determinada forma, a tendência é que a Administração Pública passe a adotar aquele entendimento, sendo a jurisprudência, por isso, considerada como fonte do Direito Administrativo.

Inclusive, no Brasil a jurisprudência ganhou força como fonte de todo o Direito em virtude dos dois institutos que seguem:

- ADIn e ADCon (art. 102, § 2º, CF, e Lei Nacional n.º 9.868/1999): as decisões proferidas pelo STF (Poder Judiciário) nas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIn) e nas ações declaratórias de constitucionalidade (ADCon) possuem eficácia *erga omnes* e efeito vinculante por expressa disposição Constitucional. Ou seja, é uma jurisprudência (decisão de Tribunal) que deve ser obrigatoriamente observada pelo Poder Executivo (Administração pública);

- Súmulas vinculantes (art. 103-A, CF): as súmulas vinculantes editadas pelo STF (Poder Judiciário) também são de observância obrigatória pela Administração pública (Poder Executivo).

Constituição Federal

Art. 102. [...]

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º [...]

Lei Nacional n.º 9.868/1999

Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

d) Costume: costumes são comportamentos reiterados (repetidos) num mesmo sentido.

Nem todos os estudiosos concordam que os costumes sejam fontes do Direito Administrativo, influenciando o Poder Executivo; mas há quem defenda que eles são capazes, sim, de gerar regras a serem observadas.

e) Precedentes administrativos: são decisões administrativas válidas (de acordo com as normas jurídicas) que passam a ser observadas em casos futuros semelhantes pela mesma entidade da Administração pública (Poder Executivo) que proferiu a decisão.

Para entender: é uma espécie de "jurisprudência administrativa".

Mas, para que os precedentes administrativos possam ser considerados fontes do Direito Administrativo, devem estar presentes dois requisitos:

- Legalidade do precedente: a decisão administrativa proferida pelo Poder Executivo que passa a ser utilizada como um precedente administrativo deve estar de acordo com a lei (as normas jurídicas), pois a Administração pública não pode ser obrigada a seguir precedentes ilegais, mesmo que emanados dela própria (a autotutela administrativa permite que a Administração, a todo momento, revise seus atos e altere seus posicionamentos, sobretudo quando ilegais);

- Inexistência de justificativa relevante e motivada para alterar o precedente: também em decorrência da autotutela administrativa, se houver motivos relevantes e justificáveis, a Administração pública (Poder Executivo) pode, a qualquer momento, alterar seus precedentes.

5. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO

5.1. Força Normativa dos Princípios

a) Positivismo: o Positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX, idealizada pelo pensador Auguste Comte (também foi expoente John Stuart Mill). Esta corrente filosófica ganhou força na Europa e perdurou até o início do séc. XX.

O Positivismo jurídico reconhecia o caráter apenas secundário dos princípios, ou seja, os princípios somente eram utilizados nos casos em que houvesse lacuna na lei (omissão).

Isso porque o positivismo está diretamente ligado à lei escrita, ao Direito positivado (daí o nome dessa escola filosófica: Positivismo).

Ocorre que esse modo de pensar permitiu as práticas arbitrárias praticadas durante a 2ª Guerra Mundial, sobretudo pelo regime Nazista, pois tais atos estavam legitimados pelas leis de então. Ou seja, foram aprovadas leis permitindo a realização das arbitrariedades praticadas durante a guerra.

b) Pós-positivismo: para que se pudesse combater as leis e práticas arbitrárias da 2ª Guerra Mundial, o pós-positivismo passa a reconhecer a normatividade primária dos princípios.

Dessa forma, os princípios passam a ser considerados normas jurídicas ao lado das leis (numa mesma hierarquia), sendo desde logo invocados para controlar a atuação do Estado, e não mais apenas de modo secundário (quando houvesse lacuna na lei).

Esse movimento é conhecido como Pós-positivismo.

c) Ronald Dworkin (filósofo estadunidense): mas o que são regras e princípios? Quais as diferenças entre eles?

É o filósofo norte-americano Ronald Dworkin quem formula a teoria que passou a ser utilizada para diferenciar regras e princípios:

- Diferenças: enquanto as regras são normas concretas (ex.: homem, mulher, prazos...), os princípios são normas abstratas (dignidade da pessoa humana, solidariedade...).

- Regras: segundo Dworkin, as regras devem ser analisadas no plano da validade, do tudo ou nada.

Isso significa que, se houver um conflito entre duas ou mais regras, uma será utilizada em detrimento da outra, vale dizer, utiliza-se uma e afasta-se completamente a outra.

Além do mais, a regra que não foi utilizada num caso específico (no caso concreto em análise), também não servirá mais para qualquer outro caso futuro.

- Princípios: de modo diverso, Dworkin fixou que os princípios devem ser analisados numa dimensão de peso ou importância (não de validade).

Isso significa que, havendo um conflito entre princípios num caso concreto, deve-se fazer uma ponderação entre eles para observar qual deles é o mais importante para aquela situação.

E, de maneira diversa ao que acontece com as regras, o princípio que não prevaleceu em determinado caso concreto continua válido e existente e pode ser utilizado em outros casos futuros.

Ex.: princípios da legalidade e da igualdade nos casos "taxi X Uber" e "licença maternidade X paternidade".

5.2. Princípios em Espécie

Os dois princípios mais importantes – as pedras de toque do Direito Administrativo – são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público.

Diz-se, inclusive, que todos os demais princípios de Direito Administrativo emanam desses dois.

Também são muito conhecidos no Direito Administrativo os princípios constantes do *caput* do art. 37 da CF/1988, os quais formam o mnemônico “L.I.M.P.E”.

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - [...]

Mas também há diversos princípios de Direito Administrativo expressamente previstos em outras normas jurídicas, merecendo destaque aqueles constantes do *caput* do art. 2º da Lei Federal n.º 9.784/1999.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. [...]

a) Princípio da supremacia do interesse público: é um dos pilares do Direito Administrativo tradicional e significa que o interesse público possui supremacia sobre o interesse privado.

Ou seja, o interesse da coletividade (público) deve sobrepor-se ao interesse egoístico de apenas um indivíduo (privado): o interesse privado jamais deve ser colocado acima do interesse público.

Mas o interesse público possui duas categorias:

- Interesse público primário: é a satisfação das necessidades públicas coletivas, como saúde, educação, segurança, transporte, bem-estar, justiça... O interesse público primário é o interesse da coletividade, da sociedade, dos cidadãos (que são a razão de ser do Estado), sendo esse o interesse que possui supremacia sobre o interesse privado;

- Interesse público secundário: já o interesse público secundário é o interesse do próprio Estado, da própria Administração Pública, que é implementado para que ele possa atender ao interesse público primário. Ex.: compra de mesas e cadeiras para os servidores do INSS trabalharem, pagamento de aluguel do prédio onde funciona um CRAS, pagamento da remuneração dos servidores públicos...

- Supremacia: o interesse público que possui supremacia sobre o interesse privado é apenas o interesse público primário, não o secundário. Dessa forma, quando se trata de interesse público secundário, não existe supremacia, mas sim igualdade entre os interesses públicos e os interesses privados envolvidos. Ex.: a Administração pública não pode deixar de pagar a remuneração dos seus servidores ou o aluguel do prédio onde funciona o CRAS (interesses públicos secundários) alegando que necessita do dinheiro para investir na saúde em virtude da Covid-19 (interesse público primário).

b) Princípio da indisponibilidade do interesse público: como o interesse público é o interesse da coletividade, ele não se encontra à livre disposição de quem quer que seja, sendo inapropriável.

Os órgãos públicos, os gestores, os governantes, os políticos, os agentes públicos... não são titulares do interesse público; eles devem zelar para que o mesmo seja sempre observado, não podendo afastar as normas públicas conforme seu livre arbítrio (isso pode ser feito no âmbito privado; jamais no âmbito público).

c) Princípio da "legalidade" (juridicidade): significa que a atuação administrativa está pautada pela lei, vale dizer, a Administração pública sempre deve observar a lei.

Aqui temos a famosa frase do doutrinador Hely Lopes Meirelles, que bem explica como o princípio da legalidade funciona no âmbito da Administração pública:

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa "poder fazer assim"; para o administrador público significa "deve fazer assim".

- Princípio da juridicidade (reinterpretação): com o pós-positivismo, o princípio da legalidade passou a ser lido como princípio da juridicidade, também chamado de "bloco de legalidade".

Isso significa que a atuação administrativa deve ser pautada não apenas pelo cumprimento da "lei" (em sentido estrito), mas de todas as normas jurídicas (Constituição, tratados internacionais, leis, normas infralegais...), inclusive pelo respeito aos princípios que regem toda a atuação administrativa (que são os princípios que estamos estudando).

d) Princípio da impessoalidade: o princípio da impessoalidade possui duas acepções, abrangendo a igualdade e a proibição de promoção pessoal. Vejamos:

- Igualdade ou isonomia: significa que a Administração Pública deve dispensar tratamento isonômico aos particulares, não podendo discriminar nem privilegiar alguém, salvo quando houver expressa previsão legal para esse tratamento diferenciado.

Ex.: processos judiciais de idosos têm preferência sobre os demais (art. 71 da Lei Nacional n.º 10.741/2003), até 20% das vagas de concursos públicos devem ser reservadas para portadores de deficiência (art. 5º, § 2º, Lei Federal n.º 8.112/1990).

- Proibição de promoção pessoal (art. 37, § 1º, CF): as realizações públicas são feitas da entidade administrativa e não dos agentes públicos que ali trabalham.

Ou seja, não é o prefeito, o governador, o presidente da Câmara... quem faz determinada realização, mas sim o Município, o Estado, o Poder Legislativo Municipal...

Lei Nacional n.º 10.741/2003

Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.

§ 1º [...]

Lei Federal n.º 8.112/1990

Art. 5º [...]

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a

deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.

Constituição Federal

Art. 37. [...]

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

e) Princípio da moralidade (art. 2º, púnico, IV, Lei Federal n.º 9.784/1999): a atuação administrativa, além de respeitar a lei (princípio da juridicidade: bloco de legalidade), deve ser ética, leal, séria, proba, de boa-fé...

Ex.: vedação do nepotismo (SV 13/STF), ação popular (Lei Nacional n.º 4.717/1965), ação civil pública (Lei Nacional n.º 7.347/1985), Lei de Improbidade Administrativa (Lei Nacional n.º 8.429/1992), Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar Nacional n.º 135/2010), Lei Anticorrupção (n.º 12.846/2013)...

Lei Federal n.º 8.112/1990

Art. 2º [...]

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

Súmula Vinculante 13

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Lei Nacional n.º 4.717/1965

Regula a ação popular.

Lei Nacional n.º 7.347/1985

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências.

Lei Nacional n.º 8.429/1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

Lei Complementar Nacional n.º 135/2010

Altera a Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9º do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato.

Lei Nacional n.º 12.846/2013

Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

f) Princípio da publicidade: a publicidade nada mais é do que a transparência que deve haver em praticamente todos os atos administrativos.

É a exteriorização e divulgação dos atos do Poder Público para conhecimento da população.

A publicidade é a regra, pois vige o direito fundamental à informação: art. 5º, inc. XXXIII, da CF e Lei de Acesso à Informação (LAI, n.º 12.527/2011).

Há vários dispositivos e instrumentos legais que nos garantem o acesso às informações públicas: direito de petição ao Poder Público (alínea 'a' do inc. XXXIV do art. 5º da CF), direito de obter certidões do Poder Público (alínea 'b' do inc. XXXIV do art. 5º da CF), mandado de segurança individual e coletivo (inc. LXIX do art. 5º da CF), *habeas data* (inc. LXXII do art. 5º da CF)...

Mas nem todos os atos do Estado são públicos, havendo exceções ao princípio da publicidade, nas quais vigorará o sigilo, que estará presente em três situações:

- *Informações imprescindíveis à segurança do Estado* (art. 23 da LAI). Ex.: ação de treinamento de tropas e testes de materiais bélicos;
- *Informações imprescindíveis à segurança da sociedade* (art. 23 da LAI). Ex.: transporte de preso de alta periculosidade não precisa, nem deve, ser divulgado;
- *Informações pessoais relacionadas à intimidade, vida privada, honra e imagem da pessoa* (art. 31 da LAI). Ex.: processos judiciais que tratam sobre "[...] casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes" (art. 189, II, CPC).

Constituição Federal

Art. 5º [...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

- a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
- b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

LXXII - conceder-se-á "habeas-data":

- a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

Art. 37. [...]

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

Art. 216. [...]

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

Lei Nacional n.º 12.527/2011

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

- I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
- II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
- III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
- IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
- V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas;
- VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
- VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
- VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

- I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e
- II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§ 2º [...]

g) Princípio da eficiência: o princípio da eficiência foi inserido no *caput* do art. 37 da CF pela EC n.º 19/1998, conhecida como reforma administrativa, e marca a substituição da Administração Pública burocrática (preocupada com os processos) pela gerencial (preocupada com os resultados).

Segundo o princípio da eficiência, a medida administrativa será eficiente quando implementar, com a maior intensidade e o menor custo possíveis, os resultados legitimamente esperados.

h) Princípio da presunção de legitimidade: os atos administrativos praticados pelo Poder Público presumem-se legítimos, ou seja, presume-se que estão fundados e amparados em lei, que são legais (praticados observando as normas jurídicas).

Isso significa que os atos administrativos não precisam passar pelo crivo do Poder Judiciário para que possam produzir efeitos. Ex.: multa de trânsito.

Mas se trata apenas de uma presunção; logo, se o destinatário do ato quiser levar a discussão ao Poder Judiciário, poderá fazê-lo, até porque, conforme já visto, no Brasil adotou-se o sistema inglês de jurisdição (jurisdição *una*), no qual é o Poder Judiciário quem decide todo e qualquer conflito de interesses com caráter de definitividade (art. 5º, XXXV, da CF).

Constituição Federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

i) Princípio da continuidade: esse princípio está ligado à prestação dos serviços públicos, que não pode ser interrompida em virtude da necessidade constante de satisfação das necessidades dos cidadãos decorrente dos seus direitos fundamentais.

Há duas acepções envolvendo o princípio da continuidade.

- Necessidade absoluta (maneira contínua): quando se tratar de necessidade absoluta, o serviço público deve ser prestado sem qualquer interrupção.

Quem vai dizer quais serviços são de necessidade absoluta são a lei, a jurisprudência e a doutrina, pois não se trata de um conceito estanque: o que não é prioridade hoje, pode ser daqui a 10 anos; o que era prioridade em 2000, talvez hoje não seja mais.

Ex.: atualmente não há dúvidas de que a *internet* é uma necessidade absoluta, sobretudo em decorrência da pandemia da Covid-19. Também são de absoluta necessidade e, portanto, não passíveis de interrupção: polícias, hospitais, água potável, energia elétrica...

- Necessidade relativa (maneira periódica): doutra banda, são de necessidade relativa os serviços públicos que podem ser prestados de maneira periódica, em dias e horários pré-determinados pelo Poder Público.

Ex.: museus, bibliotecas públicas...

Portanto, o que não pode ser interrompido são os serviços públicos qualificados como de necessidade absoluta.

Também há três outras importantes questões envolvendo a continuidade dos serviços públicos.

→ Interrupção em caso de inadimplemento do usuário (art. 6º, § 3º, II, Lei Nacional n.º 8.987/1995): o serviço público, mesmo o de necessidade absoluta, pode ser interrompido quando houver inadimplemento do usuário, pois a continuidade da sua prestação pressupõe a contraprestação pecuniária.

- Exceção (direitos fundamentais essenciais): mas a interrupção não pode ocorrer, mesmo havendo inadimplemento do usuário, quando afetar direitos fundamentais essenciais. Vejamos dois exemplos para melhor compreender:

Ex1: a concessionária de energia elétrica não pode cortar o fornecimento da energia quando há na casa pessoa doente (*home care*) que sobrevive com a ajuda de aparelhos elétricos.

Ex2: também não pode ocorrer o corte de energia ou água potável de um hospital público (mas pode cortar de um ginásio de esportes ou de uma piscina pública).

→ Greve dos servidores públicos: o STF reconheceu o direito de greve dos servidores públicos estatutários, determinando a aplicação analógica da Lei Nacional n.º 7.783/1989 (art. 37, VII, CF), mas desde que não haja paralisação total da atividade pública, em atenção ao princípio da continuidade do serviço público.

Dessa forma, a greve não pode ser de todos os servidores públicos (100%) ao mesmo tempo, pois isso causaria interrupção dos serviços públicos prestados aos cidadãos.

→ "Exceptio non adimpleti contractus": a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, não pode ser invocada pelas concessionárias de serviço público contra a Administração Pública.

Portanto, mesmo que o Poder Público esteja em débito com a concessionária (empresa privada), esta deve ingressar com ação judicial para que possa parar de prestar o serviço público (art. 39, Lei Nacional n.º 8.987/1995).

Ex.: a empresa que está construindo um prédio para a Administração Pública não pode parar a obra em virtude do atraso do Poder Público no pagamento das parcelas do preço; para tanto, a empresa deve propor uma ação judicial no Poder Judiciário.

Código Civil

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 6º [...]

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

- I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
- II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.

j) Princípio da autotutela: o princípio da autotutela é sinônimo de fiscalização e significa que o Poder Público tem o poder-dever de rever seus próprios atos a todo instante (Súmulas 346 e 473/STF e arts. 53-54 da Lei Federal n.º 9.784/1999).

Com base na autotutela, a Administração Pública tem as seguintes prerrogativas:

- Anular no prazo de 5 anos: a Administração deve anular seus atos administrativos quando eles forem ilegais (contrários às normas jurídicas). A anulação deve ser realizada no prazo decadencial de até cinco anos e terá efeito *ex tunc* (retroativo);
- Revogar: a Administração pode revogar seus atos administrativos quando inoportunos ou inconvenientes, por questões de mérito. A revogação pode ser realizada a qualquer tempo (mesmo que tenham se passado mais de cinco anos) e terá efeito *ex nunc* (apenas prospectivos).

Súmulas

S. 346/STF. A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

S. 473/STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

k) Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade (art. 2º, púnico, VI, Lei Federal n.º 9.784/1999): a proporcionalidade e a razoabilidade são distintas, mas possuem um ponto em comum, qual seja, limitar os excessos da Administração Pública.

A proporcionalidade teve origem nas teorias jusnaturalistas dos sécs. XVII e XVIII, as quais reconheceram direitos imanentes ao homem (ser humano), oponíveis ao Estado.

Já a razoabilidade nasce e se desenvolve no sistema da *common law* (costumes), sobretudo nos EUA, como forma de proteção dos indivíduos contra os abusos do Estado.

O ponto comum e a importância da proporcionalidade e da razoabilidade é que ambas buscam limitar os excessos que possam ser cometidos pelo Poder Público, sobretudo quando estivermos diante de atos discricionários, que são aqueles sujeitos à oportunidade e conveniência da Administração Pública, onde ela possui margem de escolha (≠ ato vinculado, no qual não há margem de escolha).

Há divergências, mas prevalece a tese da fungibilidade entre ambas, ou seja, que o princípio da proporcionalidade pode substituir o da razoabilidade, e vice-versa (que são iguais).

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

l) Princípio da motivação (art. 2º, púnico, VII, Lei Federal n.º 9.784/1999): o princípio da motivação significa que o Poder Público, ao praticar os atos administrativos, deve indicar as razões (motivar) pelas quais o faz.

Entretanto, é majoritário o entendimento de que a motivação não é obrigatória, nem nos atos vinculados, nem nos atos discricionários: o que é obrigatório em todo e qualquer ato administrativo é o elemento motivo (situação de fato + fundamento legal), que estudaremos no tópico "Atos Administrativos" e que não se confunde com o princípio da motivação.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

m) Outros: por fim, há uma série de outros princípios jurídicos aplicáveis no Direito Administrativo, dentre os quais se pode citar:

- *Princípio da consensualidade e participação;*
- *Princípio da segurança jurídica;*
- *Princípio da proteção da confiança;*
- *Princípio da boa-fé.*

6. QUESTÕES

- 1) ()** Nos Estados Absolutistas, os reis sequer eram responsabilizados por seus atos, pois o Estado era personificado na pessoa do próprio rei – “O Estado sou Eu.”
- 2) ()** A democracia é o traço característico do Estado Democrático de Direito, significando a participação efetiva e operante do povo na coisa pública.
- 3) ()** O surgimento do Direito Administrativo ocorre no Estado Liberal de Direito (fim do séc. XVIII e séc. XIX), decorrente da Revolução Francesa, de 1789.
- 4) ()** No Estado Social de Direito há uma preocupação com os direitos sociais e em garantir a igualdade material entre os cidadãos (não mais formal), tendo o mesmo surgido com a Revolução Russa, de 1917.
- 5) ()** O Estado Democrático de Direito é aquele que respeita a origem do poder, que é o próprio povo, que sempre o exerce diretamente.
- 6) ()** A história nos mostra que, da total ausência do Direito Administrativo e seu posterior nascimento, ele foi crescendo e tomando corpo com o passar dos anos, acompanhando e moldando a evolução dos Estados.
- 7) ()** O sistema Francês leva a separação dos Poderes ao extremo, pois os conflitos de interesse envolvendo o Poder Executivo (a Administração Pública) são decididos pelo Conselho do Estado, órgão vinculado ao Poder Legislativo.
- 8) ()** Estado Democrático de Direito é aquele que respeita o povo como verdadeira origem do poder.
- 9) ()** Muitos autores vinculam as gerações ou dimensões de direito ao lema da Revolução Francesa: “Liberdade, igualdade e fraternidade.” Dessa forma, os direitos de 1ª geração são aqueles atinentes à liberdade, exigindo uma postura absenteísta do Estado; os de 2ª geração dizem respeito à igualdade entre os cidadãos, exigindo a intervenção estatal; por fim, os de 3ª geração se relacionam à fraternidade, que são os direitos transindividuais ou metaindividuais.
- 10) ()** Apesar de o Estado Social de Direito ser aquele no qual se exige uma postura negativa do Estado na busca da igualdade material da população, foi nesse período que se consolidaram regimes ditatoriais, entre eles o nazista, com base em discursos populistas de bem-estar social.
- 11) ()** O sistema inglês é aquele em que há um único órgão que exerce a jurisdição, qual seja, o Poder Judiciário, que decide todo e qualquer conflito de interesses com caráter de definitividade, até mesmo aqueles envolvendo a Administração Pública (Poder Executivo).
- 12) ()** Segundo o ensinamento do filósofo norte-americano Ronald Dworkin, enquanto o conflito de regras deve ser analisado no plano do “tudo ou nada”, na colisão entre dois princípios deve-se fazer uma ponderação de qual seja mais importante naquela situação, de modo que a incidência de um princípio num caso concreto afasta totalmente o outro.
- 13) ()** O princípio da supremacia do interesse público, uma das pedras de toque do Direito Administrativo, informa que todo e qualquer interesse público possui supremacia sobre o interesse privado (interesse egoístico de um único indivíduo).

14) () Quando algum governante realiza promoção pessoal em publicidade do Poder Público, tem-se ferimento ao princípio da publicidade.

15) () O princípio da publicidade, regra na Administração Pública, não se sobrepõe às situações em que o sigilo se faça necessário para a segurança do Estado e da sociedade e para o resguardo de informações pessoais.

16) () A reserva de vagas em concursos públicos para portadores de deficiência é um exemplo de ação afirmativa, que visa à obtenção da igualdade formal.

17) () A expressão “interesse público” pode ser compreendida em dois sentidos: interesse público primário e secundário.

Q1003643

Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem Unificado XXIX - Primeira Fase

Luciana, imbuída de má-fé, falsificou documentos com a finalidade de se passar por filha de Astolfo (recentemente falecido, com quem ela não tinha qualquer parentesco), movida pela intenção de obter pensão por morte do pretense pai, que era servidor público federal. Para tanto, apresentou os aludidos documentos forjados e logrou a concessão do benefício junto ao órgão de origem, em março de 2011, com registro no Tribunal de Contas da União, em julho de 2014. Contudo, em setembro de 2018, a administração verificou a fraude, por meio de processo administrativo em que ficou comprovada a má-fé de Luciana, após o devido processo legal.

Sobre essa situação hipotética, no que concerne ao exercício da autotutela, assinale a afirmativa correta.

- () A) A administração tem o poder-dever de anular a concessão do benefício diante da má-fé de Luciana, pois não ocorreu a decadência.
- () B) O transcurso do prazo de mais de cinco anos da concessão da pensão junto ao órgão de origem importa na decadência do poder-dever da administração de anular a concessão do benefício.
- () C) O controle realizado pelo Tribunal de Contas por meio do registro sana o vício do ato administrativo, de modo que a administração não mais pode exercer a autotutela.
- () D) Ocorreu a prescrição do poder-dever da administração de anular a concessão do benefício, na medida em que transcorrido o prazo de três anos do registro perante o Tribunal de Contas.

Q665239

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2016 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XX - Primeira Fase

Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de concessão do serviço público metroviário em determinado Estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno ao poder concedente de todos os bens reversíveis já amortizados, quando do advento do termo final do contrato, ensejaria enriquecimento sem causa do Estado.

Assinale a opção que indica o princípio que justifica tal previsão editalícia.

- () A) Desconcentração.
- () B) Imperatividade.
- () C) Continuidade dos Serviços Públicos.
- () D) Subsidiariedade.

Q318805

Ano: 2008 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2008 - OAB - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

O diretor-geral de determinado órgão público federal exarou despacho concessivo de aposentadoria a um servidor em cuja contagem do tempo de serviço fora utilizada certidão

de tempo de contribuição do INSS, falsificada pelo próprio beneficiário. Descoberta a fraude alguns meses mais tarde, a referida autoridade tornou sem efeito o ato de aposentadoria.

Na situação hipotética considerada, o princípio administrativo aplicável ao ato que tornou sem efeito o ato de aposentadoria praticado é o da

- () A) autotutela.
- () B) indisponibilidade dos bens públicos.
- () C) segurança jurídica.
- () D) razoabilidade das decisões administrativas.

Q205060

Ano: 2008 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: OAB-SP Prova: CESPE - 2008 - OAB-SP - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

Acerca dos princípios de direito administrativo, assinale a opção incorreta.

- () A) Tanto a administração direta quanto a indireta se submetem aos princípios constitucionais da administração pública.
- () B) O rol dos princípios administrativos, estabelecido originariamente na CF, foi ampliado para contemplar a inserção do princípio da eficiência.
- () C) O princípio da legalidade, por seu conteúdo generalizante, atinge, da mesma forma e na mesma extensão, os particulares e a administração pública.
- () D) Embora vigente o princípio da publicidade para os atos administrativos, o sigilo é aplicável em casos em que este seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Q207861

Ano: 2007 Banca: VUNESP Órgão: OAB-SP Prova: VUNESP - 2007 - OAB-SP - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Sobre os princípios da Administração Pública, é correto afirmar que:

- () A) segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública pode, por meio de simples ato administrativo, criar obrigações ou impor vedações, desde que a lei não as proíba.
- () B) é consequência do princípio da impessoalidade a regra do parágrafo 1.º, do artigo 37 da CF, que proíbe a publicidade de atos de governo que se caracterizem como promoção pessoal do administrador.
- () C) os princípios da moralidade, da razoabilidade e da eficiência necessitam de regulamentação legal para que sejam aplicáveis a casos concretos.
- () D) o princípio da publicidade veda em qualquer hipótese seja atribuído sigilo aos atos praticados pela Administração Pública.

Q207086

Ano: 2007 Banca: VUNESP Órgão: OAB-SP Prova: VUNESP - 2007 - OAB-SP - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

A Lei Complementar n.º 1.025, de 7 de dezembro de 2007, do estado de São Paulo, ao criar a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP), dispôs que essa agência, no desempenho de suas atividades, deveria obedecer, entre outras, às diretrizes de "adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público" (art. 2.º, III) e de "indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinem as suas decisões" (art. 2.º, V). Tais diretrizes dizem respeito aos seguintes princípios:

- () A) eficiência e devido processo legal.
- () B) razoabilidade e objetividade.
- () C) proporcionalidade e motivação.
- () D) legalidade e formalidade.

Q208754

Ano: 2006 Banca: ND Órgão: OAB-DF Prova: ND - 2006 - OAB-DF - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

Assinale a alternativa CORRETA:

- () A) o princípio da razoabilidade somente é aplicado pelo administrador público na forma e nos casos taxativamente previstos em lei;
- () B) a motivação é obrigatória nos atos administrativos discricionários;
- () C) a motivação é obrigatória nos atos administrativos vinculados;
- () D) a desapropriação indireta, consagrada na incorporação de bem imóvel ao conjunto de bens públicos de uso especial, resolve-se em perdas e danos.

Q208747

Ano: 2006 Banca: ND Órgão: OAB-DF Prova: ND - 2006 - OAB-DF - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

Entre as tendências atuais do Direito Administrativo Brasileiro encontramos um forte movimento no sentido da ampliação da discricionariedade administrativa constatado nas idéias de substituição da Administração burocrática pela Administração gerencial e de defesa de uma maior liberdade decisória das autoridades públicas. Qual dos seguintes elementos funciona atualmente como poderoso limite à discricionariedade administrativa:

- () A) o princípio da inafastabilidade da jurisdição;
- () B) o princípio da unidade de jurisdição;
- () C) o princípio da razoabilidade (ou proporcionalidade);
- () D) o princípio do duplo grau de jurisdição.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Administração Pública Gerencial
- 1.2. Forma Federativa de Estado
- 1.3. Separação dos "Poderes" (Funções Estatais)
- 1.4. Separação dos Poderes na República Federativa do Brasil
- 1.5. Administração Pública Brasileira: Direta e Indireta
- 1.6. Centralização, Descentralização e Desconcentração
- 1.7. Órgãos Públicos (Desconcentração)

2. AUTARQUIA

- 2.1. Conceito
- 2.2. Objeto
- 2.3. Criação e Extinção
- 2.4. Natureza Jurídica
- 2.5. Regime de Pessoal
- 2.6. Patrimônio
- 2.7. Responsabilidade Civil
- 2.8. Imunidade Tributária
- 2.9. Prerrogativas Processuais

3. FUNDAÇÃO PÚBLICA

- 3.1. Conceito
- 3.2. Objeto
- 3.3. Criação e Extinção
- 3.4. Natureza Jurídica
- 3.5. Regime de Pessoal
- 3.6. Patrimônio
- 3.7. Responsabilidade Civil
- 3.8. Imunidade Tributária
- 3.9. Prerrogativas Processuais

4. EMPRESAS ESTATAIS

- 4.1. Conceito
- 4.2. Objeto
- 4.3. Criação e Extinção
- 4.4. Natureza Jurídica
- 4.5. Regime de Pessoal
- 4.6. Patrimônio
- 4.7. Responsabilidade Civil
- 4.8. Imunidade Tributária
- 4.9. Prerrogativas Processuais
- 4.10. Outras Questões

5. QUESTÕES

1. INTRODUÇÃO

1.1. Administração Pública Gerencial

a) FC 19/1998: a Emenda Constitucional N.º 19/1998, conhecida como reforma administrativa, substituiu a administração pública burocrática pela gerencial, inserindo o princípio da eficiência no *caput* do art. 37 da CRFB/1988.

→ *Administração pública burocrática*: preocupada com os processos.

→ *Administração pública gerencial*: preocupada com os resultados (princípio da eficiência).

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - [...]

1.2. Forma Federativa de Estado

a) República Federativa do Brasil (art. 18, CRFB/1988): em nosso país, adotamos a forma federativa de Estado, que é aquela na qual nações independentes se unem para formar uma única entidade soberana.

Com essa união, as nações abrem mão de sua soberania e passam a ter apenas autonomia; a soberania passa a ser da nova entidade formada.

A República Federativa do Brasil é a junção ou soma das quatro espécies de Entes Federados existentes no Brasil (RFB = U+E+DF+M):

→ *União*;

→ *Estados* (o Brasil possui 26 estados-membros);

→ *Distrito Federal*; e

→ *Municípios* (no Brasil são 5.568; em Santa Catarina são 295).

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º [...]

b) Autonomia: portanto, as nações que se unem em federação abrem mão da sua soberania e passam a ter somente autonomia – independência para tomar suas decisões livremente.

Ter autonomia significa que os Entes Federados (U+E+DF+M) possuem as cinco prerrogativas que seguem.

→ Auto-organização ("lei maior"): é a capacidade dos Entes de criarem sua própria lei maior, ou seja, sua lei mais importante.

- *União*: Constituição Federal;
- *Estados*: Constituição Estadual;
- *DF*: Lei Orgânica; e
- *Municípios*: Lei Orgânica.

→ Autolegislação (*legislar*): além de poderem criar sua própria lei maior, cada um dos Entes Federados também possui a capacidade de editar suas próprias leis.

Portanto, temos leis federais (União), leis estaduais (estados), leis distritais (DF) e leis municipais (municípios).

→ Autogoverno (*poderes*): significa que todos os Entes Federados possuem sua própria estrutura de poder, que observa a tripartição das funções estatais, quais sejam, legislativo, executivo e judiciário (lembrando que os municípios somente possuem apenas legislativo e executivo, não podendo ser criado um Poder Judiciário municipal).

→ Autoadministração (*serviços*): é a capacidade dos Entes de terem seus próprios agentes públicos (servidores públicos) para executar as políticas e serviços públicos que cada um deles entender pertinentes.

→ Autonomia financeira (*receitas*): por fim, a forma Federativa também garante que os Entes componentes da Federação tenham receitas próprias, o que se dá através dos tributos que cada um deles arrecada - a CRFB/1988 determina qual tributo cabe a cada Ente.

c) Soberania: a soberania, então, passa a ser exclusiva da Federação como um todo, ou seja, de quem passa a representar a união dos Entes autônomos.

No Brasil, é a República Federativa do Brasil quem representa a soma da União, dos estados, do DF e dos municípios (RFB = U+E+DF+M).

→ Conceito: soberania é o poder político supremo da nação dentro do seu próprio território nacional e também em suas relações internacionais (com outras nações).

Soberania é o conjunto de poderes que constituem um Estado politicamente organizado.

→ República Federativa do Brasil X União (art. 1º, I, CRFB/1988): em nosso país quem detém a soberania é a República Federativa do Brasil, que representa o Brasil em suas relações internacionais (com outras nações).

Já a União é apenas mais um dos Entes Federados que compõem a República Federativa do Brasil, sendo que todos eles possuem somente autonomia: RFB (soberania) = U+E+DF+M (autonomia).

→ Presidente da República: o Presidente da República representa tanto a União, no âmbito interno (autonomia), quanto a República Federativa do Brasil, no âmbito internacional (soberania).

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

- I - a soberania;
- II - [...]

d) Descentralização política: no Brasil foi adotada a descentralização política em três níveis de governo, quais sejam:

- *Federal:* União;
- *Estadual:* estados e DF;
- *Municipal:* municípios e DF.

1.3. Separação dos “Poderes” (Funções Estatais)

a) Montesquieu = O Espírito das leis: a teoria da separação das funções estatais foi esquematizada pelo político, filósofo e escritor francês Montesquieu durante o Iluminismo (já no fim da Idade Moderna, que perdurou do séc. XV até a Revolução Francesa), em seu livro “O Espírito das leis” – mas, ao contrário do que muitos dizem, Montesquieu não é o criador da separação das funções (poderes) estatais; ele apenas observou que a separação ocorreu e a sistematizou em seu livro, falando da importância da mesma.

Segundo essa teoria, as três principais funções estatais – legislar, administrar e julgar – não podem ser exercidas pela mesma pessoa ou órgão, pois isso cria uma concentração absoluta de poder nas mãos do soberano (rei) – na época não havia nações democráticas, mas sim impérios, os quais são governados por reis.

A separação dos poderes estatais ocorreu aos poucos durante nossa história recente, sendo fruto de insatisfações e revoltas populares contra os soberanos (reis) de então.

Portanto, a separação surge como forma de combater as Monarquias Absolutistas, que eram aquelas nas quais os reis criavam o Direito (Legislativo), aplicavam o Direito que haviam criado (Executivo) e ainda tinham domínio sobre os juízes (Judiciário), pois eram eles que escolhiam e destituíam os magistrados.

Os reis, então, cometiam inúmeras arbitrariedades contra os súditos e, obviamente, não sofriam qualquer responsabilização porque eram os “donos do poder” (legislavam, executavam e julgavam) – é desse período que temos os jargões “O Estado sou eu” e “O Rei nunca erra”.

b) Poderes X Funções: consagrou-se no meio jurídico a expressão separação dos “Poderes” estatais, mas, tecnicamente, trata-se de separação das funções estatais, pois o “poder” estatal é uma coisa só (é uno e indivisível) e pertence ao povo (não aos seus representantes).

Esse Poder, que pertence ao povo, possui uma série de funções, sendo que as três mais importantes (executar, legislar e julgar) devem ser dadas a pessoas (ou órgãos) diferentes para evitar sua concentração e abuso em sua utilização.

c) Quais são os Poderes? Os três poderes (funções) são os seguintes:

- *Poder Legislativo;*
- *Poder Executivo; e*
- *Poder Judiciário.*

d) O que é a separação dos Poderes? A separação dos poderes (funções) nada mais é do que dividir as três funções estatais mais importantes – legislar, executar e julgar – entre órgãos diversos, evitando a concentração de poder nas mãos de uma mesma pessoa (na época, os reis).

Ou seja, na atualidade, a separação de poderes evita que Legislativo, Executivo e Judiciário cometam abusos e tentem se sobrepor uns aos outros, pois a ideia é a de que um poder controle a atuação do outro: sistema dos freios e contrapesos.

A separação dos poderes é um princípio fundamental para o funcionamento das instituições públicas e base de qualquer Estado Democrático de Direito.

e) Sistema de freios e contrapesos: o sistema de freios e contrapesos, também conhecido pela expressão inglesa *checks and balances*, é uma idealização de Montesquieu (no mesmo livro "O Espírito das leis") e significa que cada um dos três Poderes (funções estatais) deve limitar-se a cumprir sua função típica;

- Funções típicas e atípicas: deve ficar claro que os três Poderes (funções) desempenham tanto funções típicas quanto atípicas; mas isso não fere o sistema de freios e contrapesos, pois o que esse sistema informa é que um Poder não deve interferir na função típica que é de outro;

- Funções típicas: (i) Legislativo: editar leis e fiscalizar o Poder Executivo; (ii) Executivo: colocar as leis em prática, administrando a coisa pública; e (iii) Judiciário: julgar os conflitos de interesse com base nas leis;

- Funções atípicas: (i) Legislativo: administrar e julgar; (ii) Executivo: legislar e julgar; e (iii) Judiciário: legislar e administrar.

f) Constituição da Córsega, 1755: a Constituição da Córsega de 1755 foi a primeira no mundo a prever, expressamente (por escrito), a separação dos Poderes estatais – chamava-se Constituição Paulina, pois seu autor foi Pascuale Paoli.

Todavia, a Córsega não é mais um país soberano: ela é uma ilha que fica entre a França e a Itália e que foi um país independente por meros 14 anos (pertencia à Itália, mas em 1755 declarou-se independente e promulgou sua Constituição; porém, em 1769 foi invadida e tomada pela França, a quem pertence até os dias atuais).

Curiosidade: Napoleão Bonaparte nasceu na Córsega, em 1769.

As Constituições seguintes que previram a separação dos Poderes foram as estadunidense (EUA, 1787) e francesa (França, 1791).

1.4. Separação dos Poderes na República Federativa do Brasil

Vejamos algumas peculiaridades sobre a separação dos Poderes em nosso país.

a) Poder Executivo:

→ *União:* Presidente da República;

→ *Estados:* Governadores;

→ *Distrito Federal:* Governador; e

→ *Municípios:* Prefeitos.

b) Poder Legislativo:

- *União*: Congresso Nacional, que se divide (sistema bicameral) em:
 - Câmara dos Deputados; e
 - Senado Federal.
- *Estados*: Assembleias Legislativas;
- *Distrito Federal*: Câmara Legislativa; e
- *Municípios*: Câmaras de Vereadores.

c) Poder Judiciário:

- *União*: Justiça Federal (comum) e Justiças do Trabalho, Eleitoral e Militar (especializadas);
- *Estados*: Justiça Estadual (comum);
- *Distrito Federal*: possui um Tribunal de Justiça, vinculado à União (art. 21, XIII, CRFB/1988); e
- *Municípios*: não possuem Poder Judiciário.

d) Cláusula pétrea (art. 60, § 4º, CRFB/1988): entre nós, a separação dos Poderes é uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal, o que significa que, neste ponto, a CRFB/1988 jamais poderá ser alterada.

Inclusive, uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir a separação dos Poderes sequer poderá ser discutida no Congresso Nacional.

→ **Cuidado**: uma emenda constitucional que preveja apenas dois Poderes estará em conformidade com a CRFB/1988, pois, em que pese passem a ser apenas dois, continuará havendo separação dos poderes.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 60. [...]

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- I - a forma federativa de Estado;
- II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
- III - a separação dos Poderes;
- IV - os direitos e garantias individuais.

e) Praça dos Três Poderes: no Brasil temos uma representação física bastante simbólica dos três Poderes (da União), que é a Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF.

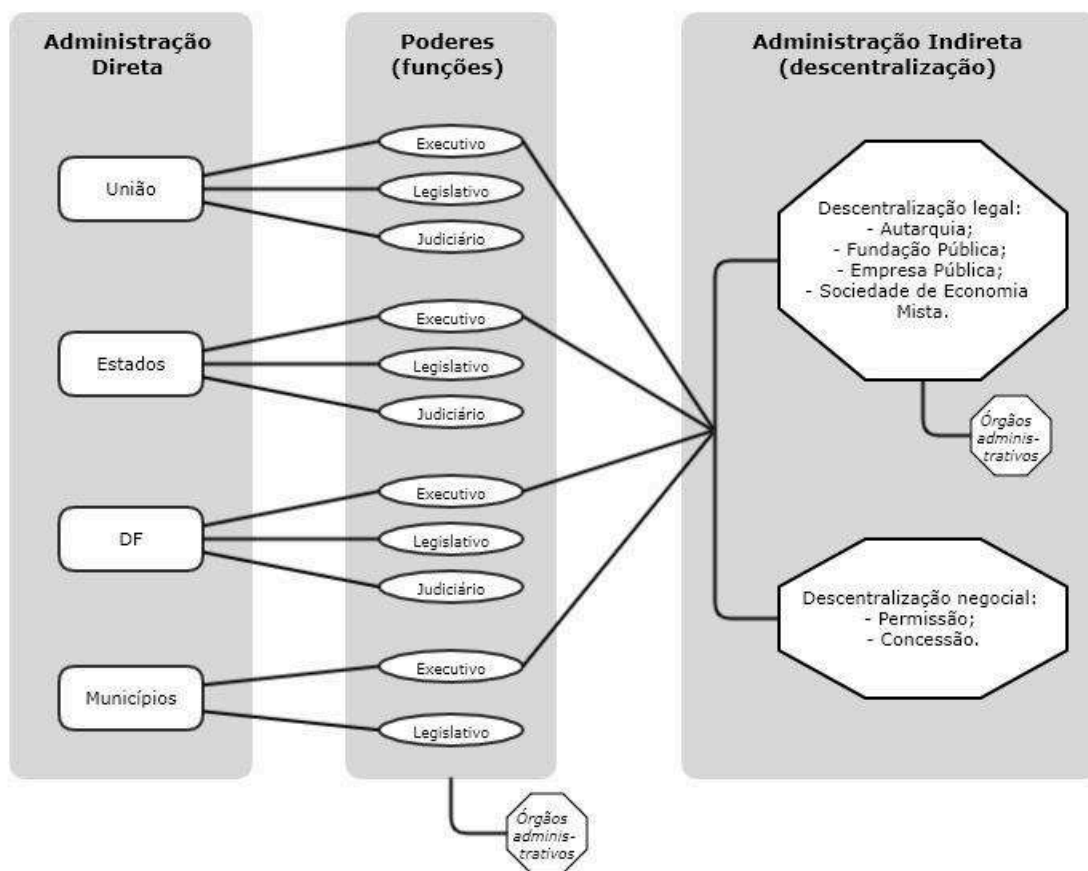
Trata-se de um amplo espaço aberto existente entre os edifícios monumentais que representam os três Poderes da República: à esquerda da praça, tem-se o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima do Judiciário brasileiro; no centro, ao fundo, há o Congresso Nacional do Brasil, que representa o Legislativo federal (curiosidade: a cúpula voltada para cima é o plenário da Câmara dos Deputados; aquela voltada para baixo

é o plenário do Senado Federal); e, à direita, temos o Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo federal.



1.5. Administração Pública Brasileira: Direta e Indireta

No Brasil, a Administração Pública divide-se em direta e indireta – veja-se o organograma que segue.



a) Administração Pública direta = Entes federados: a Administração Pública direta compreende os quatro Entes Federados antes vistos, os quais, conjuntamente, formam a Federação (República Federativa do Brasil).

- União;
- Estados;
- Distrito Federal; e
- Municípios.

b) Administração Pública indireta = entidades administrativas: as entidades administrativas são criadas pelo Poder Executivo visando, sobretudo, a melhor execução dos serviços públicos.

- Autarquia (ex: INSS);
- Fundação Pública (ex: Funai);
- Empresa Pública (ex: CEF, Correio); e
- Sociedade de Economia Mista (ex: BB, Petrobrás).

Isso tudo consta do Decreto-lei Federal N.º 200/1967: é uma norma bastante antiga e dirigida unicamente ao Poder Executivo da União (poder federal); mas ela se aplica, analogicamente, a todo o poder público brasileiro (estados, Distrito Federal e municípios). A CRFB/1988 também traz disposições a respeito em seu art. 37.

Decreto-lei Federal N.º 200/1967

Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências.

Art. 1º [...]

Art. 4º A Administração Federal compreende:

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:

- a) Autarquias;
- b) Empresas Públicas;
- c) Sociedades de Economia Mista;
- d) fundações públicas.

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

[...]

§ 2º O Poder Executivo enquadrará as entidades da Administração Indireta existentes nas categorias constantes deste artigo.

[...]

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

1.6. Centralização, Descentralização e Desconcentração

Os institutos da centralização, descentralização e desconcentração têm a ver com a prestação dos serviços públicos.

a) Centralização = Entes federados: na centralização, os serviços públicos são prestados diretamente pelos Entes federados, aos quais a Constituição Federal imputa a responsabilidade pela sua prestação.

→ Administração direta: dessa forma, na centralização os serviços públicos são prestados diretamente pelos Entes Federados (pela própria Administração direta), ou seja, pela União, estados, DF e municípios (isso é centralização).

→ Personalidade jurídica própria: os Entes Federados (Administração Pública direta) possuem personalidade jurídica própria, ou seja, são sujeitos de direitos e obrigações.

Isso significa que eles possuem capacidade judiciária e contratual, podendo contrair obrigações e pleitear por seus direitos diretamente.

→ Órgãos = desconcentração: os Entes Federados podem criar órgãos internos para a melhor distribuição das suas atividades administrativas (ex.: setores, ministérios, secretarias...).

A criação de órgãos se dá através do instituto da desconcentração administrativa, que veremos abaixo.

b) Descentralização = entidades administrativas e iniciativa privada: descentralizar é transferir a atividade para outrem.

Dessa forma, na descentralização, os Entes Federados (U+E+DF+M), que são os responsáveis primários pela prestação dos serviços públicos, delegam essa atribuição para outra pessoa (PF ou PJ).

Dito de outro modo, a Administração Pública direta transfere a prestação dos serviços públicos para uma Entidade administrativa criada para essa finalidade (Administração Pública indireta) ou mesmo para a iniciativa privada (permissão e concessão).

→ Descentralização legal = A+FP+EP+SEM: a descentralização legal é aquela que decorre do texto legal, qual seja, o art. 37, inc. XIX, da CRFB/1988 c/c art. 5º, § 2º, do Decreto-lei Federal N.º 200/1967 (acima visto).

Portanto, na descentralização legal, os Entes Federados criam uma transferência a atividade para as Entidades administrativas, quais sejam, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

→ Descentralização negocial = permissão e concessão: a descentralização negocial é aquela que decorre de um contrato administrativo (negócio jurídico), que no Direito brasileiro ocorre nos casos de permissão e concessão de serviços públicos (art. 175, *caput*, CRFB/1988), os quais decorrem de uma anterior licitação pública.

Ou seja, na descentralização negocial, o Ente Federado (U+E+DF+M) transfere a prestação dos serviços públicos para particulares (PF ou PJ), o que faz por meio de uma licitação pública (a licitação é realizada para escolher o particular que prestará o serviço público), depois da qual será assinado contrato administrativo (negócio jurídico) com o vencedor do certame (licitação).

→ Personalidade jurídica própria: nas duas modalidades de descentralização – legal ou negocial –, aqueles que prestarão os serviços públicos em nome dos Entes Federados possuem personalidade jurídica própria e, portanto, são detentores de capacidade judiciária e contratual (idem acima, em relação à Administração direta).

→ Órgãos = desconcentração: as entidades da descentralização legal (A+FP+EP+SEM) também podem criar órgãos internos para a melhor distribuição das suas atividades administrativas (idem acima em relação à Administração direta, estudo que aprofundaremos abaixo).

Já o modo de organização interna das entidades da descentralização negocial (permissão e concessão), neste ponto, não interessa ao estudo do Direito Administrativo, pois se tratam de particulares (PF ou PJ) que se submetem ao direito privado, cuja forma de organização interna (no tocante às PJ's) é livre e não interessa ao Poder Público contratante – o que interessa é que o particular (PF ou PJ) contratado para prestar o serviço público, o faça de maneira correta.

→ Controle = ausência de hierarquia (vinculação, finalístico ou supervisão ministerial): o controle que a Administração direta realiza sobre as entidades para as quais descentralizou a prestação dos serviços públicos é apenas um controle finalístico (horizontal), sem relação de subordinação ou hierarquia (vertical).

O controle por vinculação (finalístico ou supervisão ministerial) é um controle limitado.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

c) Desconcentração = órgãos: por fim, o instituto da desconcentração diz respeito à criação de órgãos administrativos internos para a distribuição das atividades dentro de uma mesma pessoa jurídica (art. 1º, § 2º, inc. I, da Lei Federal N.º 9.784/1999).

Ex: criação de setores, ministérios, secretarias, superintendências...

→ Centralização e descentralização: como visto, a desconcentração (criação de órgãos internos) ocorre tanto na centralização (U+E+DF+M) quanto na descentralização legal (A+FP+EP+SEM) – lembrando que não nos interessa estudar a forma de organização interna dos particulares (PF ou PJ) da descentralização negocial (permissão e concessão).

Ou seja, tanto os Entes Federados (centralização: U+E+DF+M) quanto as Entidades administrativas (descentralização legal: A+FP+EP+SEM) podem criar órgãos internos para melhor distribuir as suas atividades administrativas.

Ex: na autarquia INSS, há uma série de órgãos internos, como protocolo, perícia médica, concessão de aposentadorias, pagamento de benefícios...

→ Controle = hierarquia = subordinação: o controle realizado pelos Entes Federados (U+E+DF+M) e pelas Entidades administrativas (descentralização legal) sobre os órgãos da sua estrutura interna é um controle hierárquico, de subordinação (vertical), e não apenas de vinculação ou finalístico (horizontal).

Portanto, aqui são respeitados patamares de hierarquia, permitindo que os Entes e as Entidades fiscalizem, orientem e até mesmo revejam a atuação dos órgãos das suas respectivas estruturas administrativas, pois eles lhes são subordinados.

Ex.: na empresa pública CEF, o gerente-geral de cada agência possui hierarquia sobre os gerentes e demais empregados do banco; por sua vez, o gerente-geral de cada agência submete-se ao comando do superintendente regional.

Lei Federal N.º 9.784/1999

Art. 1º [...]

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - órgão: a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta;

- II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;
III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

1.7. Órgãos Públicos (Desconcentração)

Como visto acima, diferente dos Entes Federados (Administração direta = centralização = U+E+DF+M) e das Entidades administrativas (Administração indireta = descentralização = A+FP+EP+SEM), os órgãos não possuem personalidade jurídica, conforme consta do inc. I do § 2º do art. 1º da Lei Federal N.º 9.784/1999, colacionado acima.

Aqui veremos algumas peculiaridades dos mesmos.

a) Entes despersonalizados: os órgãos públicos, como unidades apenas integrantes da estrutura da Administração Pública como um todo, são entes despersonalizados, ou seja, sem personalidade jurídica própria.

Isso significa que eles não são pessoas jurídicas, mas sim um mero compartimento organizacional dentro de uma pessoa jurídica (U+E+DF+M ou A+FP+EP+SEM).

Disso decorre que os órgãos não possuem capacidade judiciária nem contratual, ou seja, os órgãos administrativos não podem contrair obrigações nem ser sujeitos de direito em nome próprio.

→ Exceção = defesa das prerrogativas institucionais: em algumas situações bastante específicas, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido que os órgãos públicos possam ser parte em processo judicial (capacidade postulatória).

Isso ocorre quando a atuação em juízo desses entes despersonalizados é necessária para a defesa de suas prerrogativas institucionais, de forma a proteger suas atividades, autonomia e independência.

Nessas hipóteses, diz-se que os órgãos passam a ser titulares de direitos subjetivos próprios a serem defendidos em juízo, do que advém sua capacidade processual excepcional.

Ex: a Mesa da Câmara dos Deputados (que é um mero órgão interno do Poder Legislativo federal) pode impetrar mandado de segurança para defender a sua competência que fora violada por um ato de outrem.

b) Ações são imputadas às PJ's às quais pertencem: dessa forma, os atos praticados pelos órgãos públicos são imputados às pessoas jurídicas às quais pertencem (Entes da Administração direta ou Entidades da Administração indireta), cabendo a estas, portanto, postular e defender direitos concernentes aos órgãos públicos que fazem parte de sua estrutura (trata-se da teoria do órgão ou da imputação volitiva, que será vista abaixo).

Ex.: quando o segurado quer propor uma ação judicial em virtude de um auxílio-doença indeferido, ele deve movê-la em face da Autarquia INSS, e não do órgão responsável pela perícia médica (setor de perícia médica).

c) Teorias dos órgãos públicos: essa teoria busca explicar a relação existente entre o Estado (poder público) e os agentes públicos que atuam em seu nome.

Chama-se de teoria dos órgãos porque os agentes públicos atuam "dentro" dos órgãos que foram criados para melhor organizar o Ente Federado (U+E+DF+M) ou a Entidade administrativa (A+FP+EP+SEM).

São três as teorias.

→ Teoria do mandato: segundo a teoria do mandato, o Estado concedeu um mandato para o agente público, que, na condição de seu mandatário, age em seu nome.

Crítica: o Estado não dispõe de vontade própria para constituir um mandato. Quem pode fazer isso são os seres humanos; o Estado é uma ficção jurídica, algo abstrato, e, portanto, não dispõe de vontade própria.

→ Teoria da representação: pela teoria da representação, o agente público é um representante do Estado.

Crítica: essa teoria equipara o Estado a um incapaz, pois são estes que precisam de representação em virtude da ausência de capacidade para contrair direitos e obrigações. Assim, se o Estado é incapaz, como ele pode escolher seus representantes? Ademais, a legislação reconhece o Estado como capaz para contrair direitos e obrigações.

→ Teoria do órgão (ou imputação volitiva): esta teoria foi formulada pelo alemão Otto Gierke no início do séc. XX e continua sendo a mais aceita até hoje.

Gierke faz uma analogia do Estado com o corpo humano, mencionando que, assim como nós, seres humanos, temos diversos órgãos atuando para manter nosso corpo em funcionamento, o Estado também tem em seu grande corpo diversos órgãos. Portanto, a atuação dos agentes públicos (que atuam dentro dos órgãos) é a vontade do próprio Estado (corpo humano).

Também é conhecida como teoria da imputação volitiva, pois a atuação dos agentes públicos é imputada ao Estado.

Curiosidade: além de jurista, Otto Gierke era médico.

d) Criação e extinção X Organização e funcionamento: a criação e a extinção dos órgãos públicos dão-se de maneira diversa que a sua organização e funcionamento:

→ Criação e extinção = lei (art. 48, XI, CRFB/1988): a criação e a extinção dos órgãos públicos devem sempre se dar por meio de Lei.

Isso significa que haverá participação do Poder Legislativo (Lei = Poder Legislativo).

→ Organização e funcionamento = decreto executivo = ausência de aumento de despesa (art. 84, VI, 'a', CRFB/1988): uma vez estando criados por meio de Lei, a organização e o funcionamento dos órgãos públicos podem ser realizados por meio de Decreto, mas desde que isso não implique aumento de despesa.

Isso significa que não há necessidade de participação do Poder Legislativo, uma vez que o Decreto é um ato privativo do chefe do Poder Executivo (Decreto = Poder Executivo).

- Aumento de despesa = lei: agora, se implicarem em aumento de despesa, a organização e o funcionamento dos órgãos também terão de ser realizados por meio de lei, vale dizer, com a participação do Poder Legislativo.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;

Art. 61. [...]

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

A partir de agora passaremos a estudar as Entidades que compõem a Administração Pública indireta, quais sejam, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista.

2. AUTARQUIA

2.1. Conceito

a) Serviço autônomo (art. 5º, I, Decreto-lei Federal N.º 200/1967): autarquia é uma entidade administrativa criada por lei, com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e receita própria, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

Portanto, as autarquias são criadas pela Administração Pública quando ela entende que determinado serviço público terá um melhor funcionamento se for executado por uma entidade específica (autarquia), a qual terá gestão descentralizada e personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios.

Decreto-lei Federal N.º 200/1967

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

I - Autarquia: o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

2.2. Objeto

a) Atividades típicas de Estado: as autarquias destinam-se a desempenhar atividades típicas de Estado, ou atividades típicas da Administração Pública, quais sejam:

- *Serviços públicos;*
- *Poder de polícia;*
- *Intervenção na propriedade; e*
- *Fomento.*

2.3. Criação e Extinção

a) Criação = lei específica (art. 37, XIX, primeira parte, CRFB/1988): as autarquias sempre devem ser criadas por lei específica, ou seja, por uma lei editada unicamente para a criação da autarquia; uma lei que não trate de outros assuntos, editada unicamente com essa finalidade.

Isso também significa que haverá participação do Poder Legislativo (Lei = Poder Legislativo) para a criação da autarquia.

→ Desnecessidade de ato posterior: publicada a lei de instituição, a autarquia estará criada sem necessidade de qualquer ato posterior.

Dito de outro modo, é a própria lei quem cria a Autarquia.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

b) Extinção = lei específica (idem): pelo princípio da simetria ou do paralelismo das formas, a extinção das autarquias também deve se dar através de uma lei específica.

2.4. Natureza Jurídica

a) Direito público (art. 41, IV, CC): as autarquias sempre têm natureza jurídica de direito público.

→ Prerrogativas do Poder público: ter natureza jurídica de direito público significa ter todas as prerrogativas do Poder Público.

As prerrogativas do Poder Públicos são os tópicos que seguem abaixo.

Código Civil

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

- I - a União;
- II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
- III - os Municípios;
- IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;
- V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.

2.5. Regime de Pessoal

a) Estatutário: como possuem natureza (personalidade) jurídica de direito público (tópico anterior), as autarquias sempre adotarão o regime estatutário para o seu pessoal, o que significa que seus agentes públicos serão contratados por meio de concurso público (classificam-se como servidores estatutários) – ou seja, as autarquias não adotam o regime celetista (CLT).

Sendo seus trabalhadores servidores públicos efetivos estatutários, eles poderão adquirir estabilidade no serviço público, o que ocorre após três anos de efetivo exercício e desde que aprovados no estágio probatório.

- Concurso público;
- Servidores públicos;
- Cargo público;
- Estatuto;
- Estágio probatório;
- Estabilidade.

2.6. Patrimônio

a) Bens públicos (art. 98 do CC): como se trata de pessoa jurídica com natureza de direito público, os bens das autarquias são públicos.

Código Civil

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

b) Regime jurídico dos bens públicos: os bens públicos possuem um regime jurídico especial, que lhes garantem as seguintes prerrogativas – essas prerrogativas serão estudadas em Direito Administrativo II, no tópico “Bens Públicos”:

- *Inalienabilidade ou alienação condicionada;*
- *Impenhorabilidade;*
- *Não onerabilidade; e*
- *Imprescritibilidade.*

2.7. Responsabilidade Civil

a) Responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6º, CRFB/1988): as autarquias respondem objetivamente pelos danos que seus agentes (servidores públicos) causarem a terceiros.

Apesar de não dizer expressamente, o § 6º do art. 37 da CRFB/1988 impõe a responsabilidade objetiva: basta provar o fato, o dano e o nexo causal entre eles – não é preciso provar a culpa *lato sensu*: dolo ou culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia).

Ou seja, o cidadão lesado em virtude da prática de um ato danoso praticado por uma autarquia, somente precisará comprovar o fato ocorrido, o dano suportado e o nexo de causalidade entre ambos, sem necessidade de comprovar que houve alguma espécie de culpa por parte da autarquia.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2.8. Imunidade Tributária

a) Impostos (art. 150, VI, 'a', c/c § 2º, CRFB/1988): as autarquias possuem imunidade tributária, o que significa que seu patrimônio, renda e serviços não podem ser tributados por impostos.

Portanto, as autarquias não pagam impostos, mas as outras quatro espécies de tributos sim:

- *Impostos (não pagam);*
- *Taxas (pagam);*

- *Contribuições de melhoria (pagam);*
- *Empréstimos compulsórios (pagam); e*
- *Contribuições especiais (pagam).*

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

[...]

§ 2º A vedação do inciso VI, 'a', é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

2.9. Prerrogativas Processuais

a) Gozam das prerrogativas processuais: sendo pessoas jurídicas com natureza de direito público, as autarquias gozam de todas as prerrogativas processuais da Administração Pública (Fazenda Pública), quais sejam:

- *Prazo em dobro* (art. 183, *caput*, CPC);
- *Intimação pessoal* (art. 183, § 1º, CPC); e
- *Reexame necessário* (art. 496, CPC).

Código de Processo Civil

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

3. FUNDAÇÃO PÚBLICA

3.1. Conceito

a) Sem fins lucrativos: as fundações públicas são entidades sem fins lucrativos que desenvolvem atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, criadas por meio de autorização legislativa, possuindo personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, patrimônio próprio e funcionamento custeado pela Poder público.

Decreto-lei Federal N.º 200/1967

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

IV - Fundação Pública: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

§ 3º As entidades de que trata o inciso IV deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações.

→ Não confundir: as fundações podem ser instituídas pelo Poder Público, quando serão fundações públicas (ex: Funai), ou por particulares, quando serão fundações privadas (ex: Fundação Xuxa Meneghel e Fundação Ayrton Senna).

O objeto do nosso estudo são unicamente as fundações públicas; o estudo das Fundações Privadas não interessa ao Direito Administrativo, mas sim ao Direito Civil (art. 44, III, e art. 62 e ss do CC).

Código Civil

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

III - as fundações.

Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.

Parágrafo único. [...]

3.2. Objeto

a) Atividades sociais relevantes (art. 62, CC): as fundações públicas não possuem finalidade lucrativa e destinam-se a desenvolver atividades sociais relevantes.

Aqui, por ausência de regramento específico, utiliza-se, por analogia, o parágrafo único do art. 62 do CC (que trata das fundações privadas).

Código Civil

Art. 62. [...]

Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de:

I - assistência social;

- II - cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- III - educação;
- IV - saúde;
- V - segurança alimentar e nutricional;
- VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- VII - pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;
- VIII - promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos;
- IX - atividades religiosas; e
- X - (VETADO).

3.3. Criação e Extinção

a) FP de direito público X FP de direito privado: as fundações públicas podem ser instituídas pelo Poder Público sob as duas espécies de regime jurídico: público e privado.

Essa escolha vai depender daquilo que o Ente instituidor (U+E+DF+M) quer para a fundação pública no tocante às prerrogativas: se quiser que ela detenha as prerrogativas do Poder Público, deve optar pelo regime jurídico de direito público; senão, pelo regime jurídico de direito privado.

Além do mais, essa opção a ser realizada pelo Ente instituidor implicará na forma de criação da Fundação Pública.

b) Fundação pública de direito público = lei específica: a fundação pública de direito público é criada do mesmo jeito que as autarquias, ou seja, através da edição de uma lei específica – publicada a lei de instituição, a fundação pública de direito público estará criada, não havendo necessidade de qualquer ato posterior (é a própria lei quem cria a fundação pública).

→ Fundação autárquica ou autarquia fundacional: as fundações públicas de direito público possuem bastante similitude com as autarquias, sendo, por isso, também chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais.

O que as diferencia é o objeto: enquanto as autarquias desenvolvem atividades típicas de Estado, as fundações públicas desenvolvem atividades sociais relevantes.

c) Fundação Pública de direito privado = ato constitutivo (art. 37, XIX, segunda parte, CRFB/1988): agora, se o Poder Público optar por uma fundação pública sob o regime jurídico de direito privado, a forma de criação é diferente.

→ Lei autorizativa: primeiro deve haver uma lei que apenas autorizará o Poder Público a criar a fundação pública.

Ou seja, o Poder Legislativo aprovará uma lei autorizando o Poder Executivo a criar uma fundação pública quando achar pertinente.

→ Inscrição do ato constitutivo (art. 45, caput, CC): a efetiva criação da fundação pública de direito privado ocorrerá da mesma forma que se cria qualquer pessoa jurídica de direito privado: com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro.

Ou seja, o que cria a fundação pública de direito privado não é a lei – a lei apenas autoriza a criar –, mas sim a inscrição do seu ato constitutivo (contrato ou estatuto) perante o Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Código Civil

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

d) Extinção: aqui também se aplica o princípio da simetria ou do paralelismo das formas, ou seja, a extinção das fundações públicas se dará da mesma forma que foram criadas, o que vai depender da sua natureza jurídica.

→ Fundação pública de direito público: extinção através da edição de uma lei específica.

→ Fundação pública de direito privado: extinção mediante averbação, no respectivo registro, do ato constitutivo de extinção (parte final do art. 45 do CC).

e) Criação X Áreas de atuação: a parte final do inc. XIX do art. 37 da CRFB/1988 menciona lei complementar.

→ Lei ordinária: para a criação de uma fundação pública de direito público, ou para a autorização da criação de uma fundação pública de direito privado, basta uma lei ordinária.

→ Lei Complementar (art. 37, XIX, parte final, CRFB/1988): a lei complementar que a CRFB/1988 exige é apenas para definir as áreas nas quais as fundações públicas (sejam de direito público ou de direito privado) poderão atuar.

3.4. Natureza Jurídica

a) Direito público OU direito privado: conforme visto no tópico acima, as fundações públicas podem ter tanto natureza jurídica de direito público quanto de direito privado.

Isso dependerá da opção do Ente instituidor: se ele quiser que a fundação pública tenha as prerrogativas públicas (da Fazenda Pública), deverá constituí-la com natureza jurídica de direito público (= Autarquia); senão, deve constituí-la sob natureza jurídica de direito privado.